

1500153-75.2022.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500153-75.2022.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500153-75.2022.8.26.0587 - Controle nº 2022/000402

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO CÉSAR MUKNICKA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia e aditamento, juntados às fls. 121/122 e 123, respectivamente, no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Manoel Neto, nº 50, Vila Sahy, bairro Barra do Sahy, nesta cidade e comarca de São Sebastião, THIAGO CESAR MUKNICKA SANTOS, qualificado à fl. 02, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 10 (dez) porções de maconha, 40 (quarenta) pedrinhas de "crack", 101 (cento e uma) pedras de "crack" e 07 (sete) pinos com cocaína, além da importância de R\$ 121,00 (cento e vinte e um reais); tudo conforme auto de exibição e apreensão de fl. 33, auto de constatação preliminar de fl. 34 e laudo pericial definitivo às fls. 191/193.

Em razão destes fatos, o réu THIAGO CESAR MUKNICKA SANTOS, qualificado à fl. 02, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Preso em flagrante delito, com fundamento nos artigos 282, 310, II e 312, do Código de Processo Penal, o réu teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 94/96).

Recebida a denúncia (fls. 147/148), o réu foi citado (fls. 156) e apresentou resposta à acusação (fls. 159/161). O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 175/179). Designada audiência, em instrução foi procedido ao interrogatório do réu e colhido o depoimento de duas testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa (fls. 210/213).

Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a Defesa, preliminarmente, sustentou a ilegalidade da abordagem e a consequente nulidade das provas produzidas, diante da tortura que o réu foi submetido, demonstrada pelo laudo de fls. 80. No mérito, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva estatal, em conformidade com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação do delito previsto no art. 33, caput, para o crime previsto no art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006. Na hipótese de condenação, requereu que a pena base seja fixada no mínimo legal. Requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, caso seja considerada a confissão informal perante os policiais, compensando-se com a agravante da reincidência. Quanto ao regime, pugnou pela sua fixação de acordo com a quantidade de pena a ser aplicada, requerendo. Pugnou, ainda, pela isenção da pena de multa. Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Quanto à preliminar aventada, não há indícios de que Thiago tenha sido torturado pelos policiais militares. Do relato seguro e coeso dos agentes públicos não é possível inferir que o réu sofreu qualquer tipo de violência.

Em que pese o relatado em interrogatório judicial, a lesão leve atestada no laudo médico juntado aos autos às fls. 80, bem como as imagens de fls. 42/43, são absolutamente incompatíveis com a alegada tortura. De maneira que, com base nas evidências dos autos, não há que se falar em ilicitude de provas.

Além disso, a versão de tortura por parte dos policiais em nenhum momento foi alegada anteriormente, tendo o réu permanecido em silêncio na unidade policial, e não encontra elementos de convicção nos autos que a ratifiquem. Nenhuma providência foi adotada por sua combativa Defesa antes da instrução, a fim de que tal fato fosse devidamente apurado pelos órgãos competentes.

Quanto ao mérito, o pedido é procedente.

A materialidade se evidenciou pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de folhas 02/04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 33, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 34, imagens de fls. 37/41, relatório final de fls. 84/85, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 191/193, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do réu.

Na fase inquisitiva, o réu preferiu manter-se calado.

Em juízo, THIAGO CESAR MUKNICKA SANTOS, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia. Alegou que foi torturado e forjado. Afirmou que é viciado em "crack" e que estava sendo procurado pelos policiais militares, ouvidos nessa data, em razão de um furto praticado pelo interrogando, cinco dias antes dos fatos, ora apurados. Admitiu que, naquela ocasião, foi abordado e revistado, sendo que consigo nada de ilícito foi encontrado, exceto a quantia de R\$ 200,00, proveniente da venda de o televisor que havia furtado. Relatou que foi pressionado pelos PM's para delatar o "receptador" e, do contrário, iriam imputar-lhe a traficância. No trajeto para a Delegacia de Polícia, os policiais passaram pelo lixão de Cambury e torturaram o interrogando e, após, exigiram a quantia de cinco mil reais para libera-lo. Como o interrogando não possuía tal quantia, exigiram, então, um revólver ou uma pistola e, novamente, o acusado afirmou que não possuía arma de fogo e, desta forma, os agentes da lei lhe imputaram a traficância. Ressaltou que nas dependências da Delegacia, o Escrivão de Polícia estranhou o fato de que o réu, já conhecido por ele, estivesse sendo preso por tráfico de drogas e não por roubo, como de costume, orientando, ainda, o réu a relatar ao juiz que havia sido forjado.

Noutro giro, o policial militar, RONALDO DA SILVA, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: na data dos fatos, 23/02/2022, juntamente de seu colega de farda, realizava o patrulhamento ostensivo em decorrência da operação "Saturação", pela Vila Sahy, neste município, quando um indivíduo, que estava parado na calçada, demonstrou certo nervosismo com a aproximação da viatura, motivando assim a abordagem policial. Em busca pessoal, com o indivíduo foram encontrados certa quantia de entorpecentes e dinheiro. Indagado, Thiago relatou aos policiais militares que é usuário de drogas e que estaria no local vendendo os entorpecentes para sustentar o vício. Ao Ministério Público respondeu: o réu é conhecido nos meios policiais pela prática de vários roubos; o local da abordagem é conhecido ponto de tráfico. A Defensora respondeu: no local da abordagem não havia mais ninguém, além do réu.

No mesmo sentido foram os relatos do policial militar RODINILSON SANTOS DE SOUZA, em nada divergindo o depoimento de ambos. Acrescentou que, em busca pessoal em Thiago foram encontradas, no bolso da bermuda, 10 porções de "maconha", 40 pedrinhas de "crack", além da quantia de R\$ 121,00 em espécie. Relata o depoente que, próximo ao local onde Thiago foi abordado, havia uma sacola plástica no chão, onde foram localizadas mais 101 pedras de "crack" e 7 emendorfs contendo "cocaína". Thiago relatou aos policiais militares que é usuário de drogas e que estaria no local vendendo os entorpecentes para sustentar o vício. No local da abordagem não havia mais ninguém, além do réu.

IGOR FAGUNDES DA SILVA, testemunha de defesa, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ouvido na condição de informante, narrou, em síntese, que: não presenciou a abordagem policial ao réu; acresceu que o réu trabalhava no bairro e mantinha bom comportamento.

Pois bem.

As declarações do réu não demonstraram harmonia com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos. A versão dada por ele é dissonante do que fora apurado durante a instrução criminal.

O réu, em juízo, afirmou que sofreu pressão e foi torturado pelos policiais militares para que delatasse o "receptador" dos bens que havia subtraído dias antes dos fatos. Nesse contexto, ainda, solicitaram quantia em dinheiro para libera-lo e, por não possuir tal quantia, solicitaram-lhe armas, que o réu também afirmou não possuir e, diante de suas negativas, imputaram-lhe a traficância. Ressaltou que nas dependências da Delegacia, o Escrivão de Polícia lhe orientou a denunciar ao juiz que havia sido forjado, entretanto, perante a mesma autoridade policial preferiu se calar acerca dos fatos (fl. 07).

Ademais, a versão de tortura ou excesso por parte dos policiais em nenhum momento foi alegada anteriormente, tendo o réu permanecido em silêncio na unidade policial, e não encontra elementos de convicção nos autos que a ratifiquem, devendo, pois, ser rechaçada no caso em comento.

A doutrina majoritária entende que:

"Cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas. A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, artigo 156, caput). Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais". GN

Ademais, o acusado também não comprovou atividade lícita, apesar de afirmar que não estava traficando.

Por outra lado, os policiais militares narraram os fatos em conformidade com as provas dos autos. O PM SILVA, em juízo, narrou que realizava patrulhamento pela Vila Sahy, local conhecido pelo comércio de drogas, quando visualizaram o réu e, por esboçar nervosismo e ser conhecido pelas práticas criminosas, foi abordado. Em

revista pessoal localizaram consigo entorpecentes e dinheiro em espécie. Segundo o PM, Thiago confessou informalmente que estaria no local vendendo os entorpecentes para sustentar o vício, pois é usuário de drogas. No mesmo sentido, o PM SOUZA, que salientou que, além das drogas encontradas nas vestes do réu, próximo ao acusado foi, também, localizada uma sacola contendo 101 pedras de "crack" e 7 emendorfs contendo "cocaina". Confirmou que Thiago confessou informalmente que estaria no local vendendo os entorpecentes para sustentar o vício, pois é usuário de drogas. Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado diante das provas produzidas.

Os policiais prestaram depoimentos coesos, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que os policiais tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável. Ressalte-se que não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade do testemunho policial.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias em que se deu a prisão são fatores que, associados à prova produzida, levam à certeza de que o réu efetivamente se dedicava à mercancia de entorpecentes - PENA - MULTA - QUANTUM - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - O preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena - A quantidade da pena de multa cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade - Opção de política criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes - Julgador que, no momento do cálculo da pena, deverá observar as especificidades do caso concreto - Condenação mantida- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO" (TJSPAp.n. 0084921-43.2010.8.26.0000 - 15ª Cam. Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA j. 16.12.2010) - gn.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF: "A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização". (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Além disso, a quantidade e natureza das drogas apreendidas (10 porções de maconha, 40 pedrinhas de "crack", 101 pedras de "crack" e 07 pinos com cocaína), a forma de acondicionamento, individualizadas e prontas para comercialização (imagens de fls. 37/41), a importância apreendida em notas diversas (R\$ 121,00), as contradições e a inércia do réu no sentido de provar suas alegações (onus probandi - CPP, artigo 156, caput), evidenciam que as drogas eram destinadas ao consumo de terceiros, não

havendo falar-se em insuficiência probatória. Saliente-se que o réu admitiu o tráfico informalmente, ostenta maus antecedentes, bem como é reincidente. Incabível a desclassificação da conduta para a de posse de entorpecentes para consumo pessoal, devendo o réu ser condenado pelo crime de tráfico de drogas, pois suficientes as provas de materialidade e autoria delitivas. Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado e a diversidade revelam que as drogas não se destinavam ao consumo pessoal do réu. Frise que, em juízo, o acusado sequer admitiu que estava na posse de entorpecentes.

Quanto ao requerimento da Defensoria, acerca da isenção da pena de multa, ressalto que a pena de multa é cumulativa à pena corporal e não alternativa, sendo impossível a isenção de o seu pagamento. Ademais, é pacífico o entendimento de que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, portanto, descabida a pretensão de afastamento da pena de multa. Diante de todo o exposto, resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem o réu de sanção.

Na primeira fase, verifica-se pelas folhas de antecedentes em apenso, que o réu ostenta maus antecedentes. Assim, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A quantidade de droga apreendida não extrapola os limites vistos na jurisprudência, não havendo razão para exasperar a pena base.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo que a réu é reincidente específico (fls. 67 - Roubo Majorado), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, tornando-a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há que se falar em aplicação da atenuante genérica com base em confissão informal. Em juízo, o réu não admitiu a prática delitiva, aliás apresentou graves acusações por crime de tortura e corrupção em face dos agentes da lei, dessa forma, incabível a aplicação de tal atenuante. Nesse sentido: "A referência feita pelo militar à confissão informal, como simples narrativa da operação que redundou na prisão do apelante, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea" (TJ-MG - APR: 10701190162555001 MG, Relator: Dirceu Wallace Baroni, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020).

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo o réu portador de maus antecedentes e reincidência pela prática de roubo majorado, não faz jus ao benefício. Mantida, portanto, a pena fixada na fase anterior, qual seja, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O regime inicial será o fechado, sendo o adequado ao cumprimento de pena, diante dos maus antecedentes e a reincidência, na forma do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal. Nesse sentido: "O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal". STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel.Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, considerando a quantidade de pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência (Art. 44, I, II e III, CP). Pelo mesmo motivo, sobretudo pela quantidade de pena aplicada, não há que se falar em suspensão condicional da pena (Art. 77, CP).

Inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, bem como considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, não há detração a ser procedida no momento, para fins de determinação de regime inicial mais brando, nos termos da Lei 12.736/2012. Para tanto, remeto à VEC a aplicação do art. 387, §2º, CPP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência

CONDENO: THIAGO CESAR MUKNICKA SANTOS, qualificado à fl. 02, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, no regime prisional inicial fechado por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento da multa.

Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade. Ele permaneceu preso durante a instrução em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva, pois concorrentes os motivos ensejadores da prisão preventiva. De fato, o delito de tráfico possui grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminosa, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a custódia cautelar do réu é necessária para a garantia da ordem pública. Aliás, se antes do julgamento de mérito que considerou o acusado culpado estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação – TJSP, MS 113.332-3, Rel. Reynaldo Ayrosa. Ademais, há risco concreto de reiteração delitiva, considerando seus maus antecedentes e a reincidência.

Recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

O réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro com ele apreendido, razão pela qual decreto a sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Quanto ao aparelho celular apreendido, comunique-se a Autoridade Policial para que determine sua destinação, na forma do artigo 516 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça: "Art. 516. Findo o processo, o inquérito policial, o termo circunstanciado ou o procedimento de apuração de ato infracional, não havendo deliberação judicial noutro sentido, será comunicada à Autoridade Policial para que dê destinação aos objetos, na forma dos artigos 120 a 123 e 133 do CPP".

Oficie-se à Delegacia autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal do réu, expeça-se o necessário quanto aos valores, aparelho celular e às drogas.

Cumpra-se

P.I.C.

Sao Sebastiao, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA